

<입문-제7장 행정의 실효성 확보수단.제2절 대집행>

I. 대집행의 의의

1. 개념

- 대집행이란 행정법상 의무자가 공법상 대체적 작위 의무를 이행하지 아니하는 경우, 당해 행정청이 스스로 의무자가 해야 할 행위를 대신 행하거나 제3자로 하여금 대신 행하게 하고, 그 비용을 의무자로부터 징수하는 행정강제 수단을 말한다. 이는 의무 이행을 간접적으로 확보하는 수단으로, 행정의 실효성을 담보하는 핵심적인 제도이다.

2. 법적 근거

- 대집행은 국민의 권리·자유를 침해하는 행정강제이므로 반드시 법률의 근거가 필요하다. 일반법으로는 행정대집행법이 있으며, 이 법에 의하여 대집행이 가능하지 아니한 경우에도 개별법에 특별한 규정이 있으면 그 규정에 따라 대집행을 할 수 있다.

3. 직접강제와의 차이

- 대집행은 대체적 작위 의무의 이행 확보를 목적으로 한다는 점에서, 비대체적 작위 의무 또는 부작위 의무를 불이행할 때 의무자의 신체 또는 재산에 직접적인 실력을 가하여 의무 이행을 실현하는 직접강제와 구별된다. 대집행은 제3자를 통하여 집행할 수 있지만, 직접강제는 제3자를 통할 수는 없고 행정청 자신이 직접 집행하여야 한다. 또한, 대집행의 비용은 의무자가 부담하지만 직접강제는 행정청이 부담한다.

II. 대집행의 주체와 법률관계

1. 당해 행정청

- 대집행의 주체는 원칙적으로 해당 의무를 명한 당해 행정청이다. 행정대집행법 제2조는 대집행 주체를 당해 행정청으로 명시하고 있다. 이는 법률상 대집행을 수행할 권한을 가진 행정기관을 의미한다.

2. 다른 행정청

- 당해 행정청이 직접 대집행을 실행하기 어려운 경우에는 다른 행정청에 대집행을 위탁할 수 있다. 이 경우, 대집행의 권한은 여전히 위탁한 당해 행정청에 있으며, 위탁받은 다른 행정청은 단지 사실 행위를 대행하는 것에 불과하다. 대집행에 관한 모든 법적 책임은 당해 행정청에 귀속된다.

III. 대집행의 요건

- 대집행은 국민의 권리·자유에 대한 강제력이 크기 때문에, 행정대집행법 제2조에 따라 엄격한 요건을 충족해야만 발동될 수 있다.

1. 공법상의 대체적 작위 의무의 불이행

- 대집행이 발동되기 위해서는 먼저 의무가 공법상의 것이어야 하며, 그 의무가 대체적 작위 의무여야 한다.

(1) 공법상의 의무

- 사법상의 의무 불이행에는 대집행이 적용될 수 없다.

(2) 작위 의무

- 부작위 의무(하지 말아야 할 의무)의 위반은 대집행의 대상이 될 수 없으며, 행정청이 철거 명령 등 작위 의무를 부과해야 대집행이 가능해진다.

(3) 대체적 의무

- 의무자 본인이 아니더라도 제3자가 대신하여 이행할 수 있는 의무를 말한다. 건물 철거 의무 등은 대표적인 대체적 작위 의무이다. 비대체적 의무(영업 보고 의무)의 불이행에는 대집행 대신 이행강제금이 적용된다.

(4) 불이행

- 의무를 이행하지 않은 상태여야 한다.

2. 다른 수단으로써 그 이행을 확보하기가 곤란할 것-보충성

- 대집행은 의무 이행 확보를 위한 행정청의 최후적·보충적 수단으로 기능한다. 즉, 다른 수단(비송사건절차법에 따른 과태료 부과 등)으로는 의무 이행을 확보하기가 어렵거나, 의무자의 자진 이행을 기대할 수 없는 경우에 한하여 대집행이 허용된다. 이 요건은 비례의 원칙과 관련하여 중요한 의미를 가진다.

3. 불이행을 방치함이 심히 공익을 해할 것

- 의무 불이행을 방치하는 것이 심히 공익을 해하거나 또는 인근 주민에게 중대한 위해를 끼칠 우려가 있는 경우에 한하여 대집행이 허용된다. 이 요건은 대집행 발동의 공익적 필요성을 담보하는 기준이다.

IV. 대집행의 절차

- 대집행은 법적 안정성과 의무자의 방어권 보장을 위해 4단계의 엄격한 절차를 거치는 것이 원칙이다.

1. 계고

- 계고는 의무자에게 의무 불이행 사실, 대집행의 내용 및 범위, 대집행에 필요한 비용 등을 문서로써 알리고, 일정한 기간까지 의무를 이행하지 않으면 대집행을 실시한다는 뜻을 사전에 통지하는 행위이다.

(1) 처분성

- 계고는 국민의 권리·의무에 직접적인 영향을 미치는 행위로서, 취소소송의 대상인 처분으로 인정된다는 것이 판례의 태도이다. 다만, 반복된 계고의 경우는 이를 부정한다.

(2) 하자 승계

- 1차 계고와 2차 계고 사이에 하자의 승계 문제가 발생할 수 있다.

2. 대집행 영장에 의한 통지

- 의무자가 계고에 정한 기간 내에 의무를 이행하지 아니한 경우, 행정청은 대집행을 실행하기 전에 대집행 영장을 의무자에게 발부하고 통지해야 한다. 통지서에는 대집행을 행할 시기, 대집행을 행할 책임자의 성명 등을 명시해야 한다. 이 통지는 계고와 달리 처분성이 부정되며, 단순한 사실의 통지로 본다.

3. 대집행의 실행

- 대집행 영장에 기재된 시기에 대집행 책임자(또는 위임을 받은 자)가 현장에 출장하여 실제로 의무를 대신 이행하는 행위이다. 대집행의 실행은 사실 행위로서, 위법한 실행이더라도 그 자체로 처분성이 인정되지 않으며, 손해 발생 시 국가배상의 대상이 된다.

4. 대집행 비용의 징수

- 대집행에 소요된 비용은 의무자로부터 징수한다. 행정청은 비용에 관하여 국세 징수의 예에 따라 강제 징수할 수 있으며, 이 때 비용 납부를 명하는 납부 명령은 강제 징수 절차의 시작으로써 처분성이 인정된다.

V 결론

- 대집행은 공법상 대체적 작위 의무의 이행을 간접적으로 확보하는 행정강제 수단이다. 이는 법률의 근거, 보충성, 공익성의 요건을 엄격히 충족해야 하며, 계고-통지-실행-징수의 4단계 절차를 거쳐야 한다. 특히, 계고 처분의 취소소송 가능성 등 쟁송법상 쟁점이 중요하게 다루어진다.